

1500367-95.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Supremo Tribunal Federal, o chamado "tráfico privilegiado" não é considerado como crime equiparado aos hediondos, permitindo a substituição.

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado por policiais militares comercializando drogas. Apreensão de 2 tubos plásticos contendo cocaína, pesando 3 gramas, e 27 pedras de crack, pesando 11,5 gramas, além de R\$ 80,00. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500367-95.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-95.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090202/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 17123244 - DEL.POL.APARECIDA, 723/21/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2090202 - DEL.POL.ROSEIRA, 723/21/201 - DEL.POL.ROSEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLODOALDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública contra CLODOALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, apontando-o como transgressor do disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 13h30min, na via pública, nas proximidades da Rua João Damasceno dos Santos, nº 111, bairro Pedro Leme, nesta cidade, o acusado, trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12 microtubos, tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando aproximadamente 11,86g, 20 porções de cocaína, na forma sólida (pedra), também conhecida como "crack", pesando aproximadamente 8,1g, e 21 porções de substância vulgarmente conhecida como "maconha", pesando

aproximadamente 30,77g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. Segundo descreve a peça acusatória que dá início ao procedimento, o acusado trafegava de bicicleta pela cidade, sendo que ao notar a aproximação da viatura policial rapidamente mudou o sentido de direção, tentando disfarçar ao se aproximar de um pedestre. O comportamento despertou fundada suspeita por parte dos policiais, que resolveram efetuar sua abordagem, quando encontraram sob suas vestes uma sacola plástica contendo os entorpecentes acima descritos. Finaliza a acusação dizendo que a forma de armazenamento do entorpecente torna clara a finalidade de comercializar os entorpecentes.

Em cumprimento ao disposto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06 o acusado foi notificado e apresentou a defesa preliminar de fls. 154, sem, contudo, suscitar preliminares ou arrolar testemunhas.

Denúncia ministerial acolhida pela decisão de fls. 161.

Durante a fase de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu, que confessou a posse dos entorpecentes, bem como sua finalidade mercantil - fls. 177 a 179 - audiência por videoconferência.

Em sua derradeira manifestação o Ministério Público propôs a condenação do acusado, apoiando-se no acervo probatório compilado pela instrução criminal. Sustentou que os depoimentos dos policiais deram conta da autoria do delito de tráfico por parte deste agente, somados ao encontro da droga, em quantidade considerável, circunstâncias suficientes ao reconhecimento da procedência da ação penal, não havendo razão alguma para que os policiais incriminassem falsamente o réu, que acabou por confessar a autoria do crime a ele imputado. No que se refere à pena, ponderou por sua fixação no mínimo legal, observando-se a menoridade do agente, com a incidência da causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e regime carcerário aberto (fls. 199).

Em sentido oposto veio a pretensão da defesa do acusado, dizendo que inexistem provas suficientes de que o acusado tenha realizado quaisquer das condutas núcleo do tipo penal do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Aposta na aplicação do princípio "in dubio pro reo". Defendeu a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do regime menos austero de cumprimento de pena, com a redução da pena no máximo permitido (fls. 220).

É o breve apanhado do processo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Demonstrou-se a materialidade do delito apurado nos autos por meio do Exame Químico Toxicológico de fls. 85, reforçado pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e também pelo laudo de constatação provisória de fls. 18. Submetidas as substâncias em questão ao denominado Exame Químico Toxicológico, constatou-se que, de fato, cuidava-se de cocaína e "Cannabis sativa L", conhecida no jargão popular como "maconha". A presença constatada pelo laudo pericial da substância tetrahidrocanabinol (THC) não deixa margem a dúvida de seu atributo psicotrópico, capaz de causar dependência psíquica, incluída, portanto, na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98, republicada no Diário Oficial da União de 01/02/99 e a RDC nº 18, da Agência de Vigilância Sanitária, datada de 28/01/03, satisfazendo a exigência contida no artigo 158 do Código de Processo Penal, na medida em que a infração penal apurada nos autos é daquela que deixa vestígios ("delicta facti permanentis").

Da mesma maneira a autoria do crime em questão desponta da prova angariada de forma

robusta e coesa, que contou, inclusive, com a confissão por parte do acusado.

A prova testemunhal colhida sob o manto do contraditório também é inegavelmente contrária a eventual desclassificação ou desvinculação do réu com relação às drogas apreendidas.

O policial militar FABIANO AUGUSTO COELHO SANTOS (fls. 179 - audiência por videoconferência), relatou com minúcias a bem sucedida ação, precedida de uma abordagem que localizou em poder do agente os entorpecentes apreendidos. Relatou que assim que o réu percebeu a aproximação da viatura policial, mudou repentinamente de direção, comportamento que despertou a atenção, motivo pelo qual resolveram efetuar a sua abordagem. Em poder do agente localizaram uma sacola, em cujo interior estavam as drogas relacionada na denúncia. Ao ser questionado, disse apenas que guardava os entorpecentes para um terceiro, mas disse não poder revelar seu nome ou qualquer outro elemento para sua identificação.

Não resta a menor dúvida de que a droga apreendida naquela oportunidade pertencia ao acusado e era destinada ao tráfico, inversamente do que tentou fazer crer a combativa defesa. A quantidade apreendida não é nada desprezível, principalmente por se tratar de "maconha", "crack" e cocaína, que são comercializadas em peso quase que insignificante, consumida em pequenas porções. O fato de o acusado ficar em silêncio na etapa policial, embora seja um direito constitucional, chama a atenção.

Muito embora o direito ao silêncio seja garantido aos acusados, inclusive imperativo constitucional, essa postura me parece incompatível com quem é inocente e se vê acusado de algum crime. É natural, em tais circunstâncias, que a pessoa acusada se defenda, ainda que simplesmente negando os fatos.

"Embora constitucionalmente garantida a possibilidade de o acusado permanecer em silêncio na fase extrajudicial, não se pode ter como plausível que alguém inocente admita ser injustamente apontado como autor do delito e não manifeste nenhuma oposição, sendo certo que, mesmo que o silêncio não deva ou não possa ser interpretado em desfavor do acusado, não é lógico ou normal do ser humano a passividade diante de uma infundada acusação, máxime se inexistem sinais de que tenha sido compelido a se calar naquele procedimento investigatório, uma vez que, a só quietude do réu não basta para fundamentar um decreto condenatório, mas pode servir como parâmetro para um convencimento judicial desfavorável" (TACrimSP - Ap. nº 1.305.945/2 - Lençóis Paulista - 11ª Câmara - Rel. Pires de Araújo - 24.6.2002 - v.u).

"PROVA - Interrogatório judicial - Silêncio do réu - Eficácia: - Inteligência: artigo 61, I do Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, IV do Código Penal. O silêncio do réu, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, é atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo assim a oportunidade de esclarecer, de pronto, algum equívoco de seus acusadores" (TACrimSP - Ap. nº 1.129.029/8 - 15ª Câmara - Rel. Fernando Matallo - J. 14.01.99 - RJTACRIM 43/228).

O comportamento do acusado na data dos fatos, que mudou rapidamente o rumo de sua direção e ainda tentou disfarçar fazendo contato com um transeunte, a forma de acondicionamento das drogas, sua quantidade e variedade, deixam evidente a posse das drogas para o comércio clandestino.

Não há como não acreditar na versão da polícia. Ressalte-se que os homens da força pública são agentes credenciados pelo Estado e como tal merecem confiança especial em seus relatos, ainda mais se coerente com a prova amealhada em juízo. De resto, a defesa não conseguiu comprovar qual a razão de eventual comportamento indigno dos policiais.

Afora isso, não é possível que se alegue que os testemunhos apenas de policiais não são válidos para servir de lastro a embasar o decreto condenatório, tema já exaustivamente debatido nos tribunais, cuja conclusão majoritária é no sentido de seu total acolhimento, ainda mais se amparado em outras provas colhidas, conforme sucede na espécie.

A idoneidade dos agentes da polícia, como já frisado, é presumida e somente pode ser vencida através de prova plena e inequívoca, esta ausente na hipótese "sub judice".

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição" (RT 614/275).

Significante também é a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e que não pode ser singelamente ignorada, da qual poderiam ser extraídas inúmeras pequenas porções, o que permite concluir de modo indubitado que as drogas apreendidas naquela data eram destinadas ao consumo de terceiros e que tantas famílias tem destruído ao longo dos tempos.

"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, relevante é a verificação da quantidade da substância proibida apreendida, a fim de se cotejar esse elemento com outras circunstâncias que envolvem a prática da infração, máxime quando se pretende provar que alguém é mero usuário e não traficante" (JUTACRIM 54/315).

"Tóxicos - Traficância - 7,24 g de cocaína e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente, 144, 145 "carreirinhas".... (RJTJRS 159/192).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papérolas de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n. 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

"Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no art. 12 da Lei nº 6.368/76" (RJTJRS 145/115).

Por fim, o réu é confitente, o que corrobora os relatos feitos pelos policiais em solo judicial e policial - fls. 179 - audiência por videoconferência.

"... Uma das características da confissão, como prova, é a da relatividade de seu valor. Por isso, o juiz deve confrontar a confissão com os demais elementos probatórios dos autos para ver se é compatível com estes. Já a confissão extrajudicial é insuficiente, por si só, para lastrear a condenação, embora possa ser admitida como prova suficiente quando amparada por outros elementos..." (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTERPRETADO - pg. 250 - JÚLIO FABBRINI MIRABETE).

"CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - Harmonia com os demais elementos dos autos - Condenação - Possibilidade - Posterior retratação - Irrelevância: A confissão extrajudicial, em harmonia com os demais elementos dos autos, é suficiente para autorizar condenação, inobstante posterior retratação em Juízo" (Apelação nº 819.013/6 Julgado em 22/09/1.993, 9ª Câmara, Relator: - Evaristo dos Santos, RJDTACRIM 19/75).

"PROVA - Confissão extrajudicial Valor: A confissão extrajudicial, em harmonia com os demais elementos dos autos, é suficiente para autorizar condenação, inobstante posterior retratação em Juízo" (Apelação nº 934.747/1, Julgado em 12/04/1.995, 9ª Câmara, Relator: - Evaristo dos Santos, RJDTACRIM 27/162).

Concluindo sem sobra de dúvidas de que o réu merece a censura penal, passo agora a dosimetria da pena a ser imposta, observado o sistema trifásico previsto pela legislação penal - artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Não há registros de outros envolvimento com a criminalidade. A quantidade de drogas apreendida, embora não possa ser rotulada de modesta, também não autoriza o aumento previsto pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena-base do acusado em cinco (05) anos de reclusão.

A confissão é atenuante genérica, na forma do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, contudo, como a pena-base já foi arbitrada no mínimo, não há qualquer modificação a ser feita, pois as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo.

"PENA - Redução - Inadmissibilidade - Fixação no mínimo legal - Circunstâncias atenuantes que não tem o condão de reduzi-la abaixo do mínimo - Recurso não provido. As atenuantes não permitem a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei para o crime" (Apelação Criminal n.º 151.790-3 - Barueri - Relator: Breno Guimarães - 2ª Câmara Criminal - V.U. - 07.08.95.).

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 traz causa especial de redução de pena ao dispor que nos delitos definidos no "caput" e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo o caso do acusado que realmente merece a redução pleiteada, principalmente por ter confessado.

Desse modo, reduzo a pena do acusado em 1/2, considerando a natureza das substâncias e quantidade, totalizando dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão.

Não sendo encontradas outras causas, especiais ou gerais, de aumento ou diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

A multa prevista de forma cumulativa deve ser fixada dentro dos mesmos critérios para o encontro da pena-base. No tocante ao valor, deve-se ter em mira o conteúdo do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/06, sempre no mínimo legal frente à situação econômica nada privilegiada do réu, que estava preso até a data da audiência.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime ABERTO, considerando a pena imposta ao acusado, somada às circunstâncias judiciais favoráveis previstas

pelo artigo 59 do Código Penal, máxime pela confissão, observando-se o disposto no artigo 115 da Lei de Execução Penal.

Pela ausência de pressuposto objetivo (quantidade da pena) é negado ao réu o benefício do "SURSIS" (artigo 77, "caput", do Código Penal).

É possível contemplar o acusado com uma das penas alternativas introduzidas pela Lei nº 9.714/98. As penas aplicadas não superam a 04 anos de prisão, preenchendo o agente as demais condições subjetivas consagradas pelo artigo 44 e respectivos incisos do Código Penal. No mais, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o chamado "tráfico privilegiado" não é considerado como crime equiparado aos hediondos, permitindo a substituição.

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado por policiais militares comercializando drogas. Apreensão de 2 tubos plásticos contendo cocaína, pesando 3 gramas, e 27 pedras de crack, pesando 11,5 gramas, além de R\$ 80,00. Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, corroborados pelas declarações do usuário e confissão do acusado. Insurgência defensiva em face da pena e regime aplicados. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da pouca quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo" (TJSP - Apelação Criminal 0000855-91.2018.8.26.0472; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Ferreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).

"Tráfico de entorpecentes. Preliminar não acolhida. Ingresso no imóvel que foi franqueado pela proprietária e estado de flagrância que permite a ação imediata da polícia. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão e validade dos depoimentos dos policiais e de testemunha isenta. Condenação acertada. Pena reduzida. Fixação da fração intermediária de redução em razão da quantidade do tóxico. Possibilidade de concessão do regime aberto. Ré primária e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso parcialmente provido" (TJSP - Apelação Criminal 0000086-51.2017.8.26.0591; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

"TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos probatórios. Necessária a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado. Recurso provido" (TJSP - Apelação Criminal 1500932-12.2019.8.26.0530; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

Embora a condenação (pena imposta) tenha sido superior a um ano, com possibilidade de se operar a substituição por duas penas restritivas de direitos, entendo que a prestação de serviços à comunidade já é mais do que suficiente à prevenção e repressão, na medida em que o crime também prevê pena pecuniária cumulativa, não havendo necessidade de fixação de nova multa ou mesmo prestação pecuniária, somando-se à nada confortável situação econômica do acusado.

"Tem-se definido a pena como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, por meio da ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico; seu fim é evitar novos delitos. Tem

ela esta função preventiva geral, com fim intimidativo a todos os destinatários da norma penal, e especial, dirigida ao autor do delito para o impedir de cometer novos crimes e reintegrá-lo socialmente" (Código Penal Interpretado - pg. 250 - Júlio Fabbrini Mirabete).

Quanto à prestação de serviços à comunidade, esta deverá ser executada em local a ser indicado na ocasião da audiência admonitória, com observância do artigo 46 e respectivos parágrafos.

No caso de descumprimento das condições impostas, na conversão deverá ser observado o que dita o artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Sendo o réu contemplado com a substituição acima, não há falar-se em concessão da Suspensão Condicional da Pena ("SURSI") - artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Considerando que o artigo 44 do Código Penal preconiza que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, persiste a multa imposta cumulativamente.

Em razão da substituição realizada, do regime carcerário imposto, permite-se ao réu eventual apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal, CONDENANDO o acusado CLODOALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (R.G. nº 62.078.593) por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão (REGIME ABERTO) e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente (salário mínimo paulista), na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, de conformidade com os artigos 43, inciso I, c.c. 44, § 2º, parte final, c.c. 46 e parágrafos, todos do Código Penal, mantida a pena de multa.

Ficam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas quando da revogação da prisão preventiva até que se inicie o cumprimento da pena aplicada.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
Juiz de Direito

Roseira, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA